

1512906-90.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512906-90.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512906-90.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315841/2020 - 01º D.P. AMERICANA, 15286514 - 01º D.P. AMERICANA, 962/20/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2315841 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAGBERTO APARECIDO SOLDERA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

DAGBERTO APARECIDO SOLDERA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada, tentou subtrair, para si, 05 quilos de cabos elétricos, avaliados em R\$100,00, pertencentes, dentre outros, a J.D.A.C., não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2021 (fls. 155/156).

O réu foi citado (fls. 212), apresentando defesa (fls. 164/165).

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha arrolada, bem como o réu foi interrogado (fls. 227/228).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 232/237), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada parcialmente procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto simples tentado.

O Doutor Defensor do réu requereu a absolvição em razão do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificado, o reconhecimento da atenuante e da tentativa (fls. 240/247).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, tendo em vista que não foi configurada a qualificadora da escalada.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 07/09 e 10/12, e laudos de fls. 141/143 e 145/147.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: “Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las

Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A vítima/testemunha José, ouvida apenas na Delegacia (fls. 04), informou que estava passando pela residência e visualizou "um indivíduo subindo próximo a janela retirando partes dos fios", momento em que acionou a polícia.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

O Policial Miliar Murilo esclareceu que estavam em patrulhamento e foram informados acerca de um furto em andamento. Dirigiram-se ao local, e visualizaram, por baixo da grade do portão, o réu com um alicate na mão, e colocando fios de cobre já cortados em uma sacola. O réu pulo o muro para o exterior da casa, e efetuaram a abordagem.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a pratica do delito, sendo que tentou efetuar a subtração dos fios. Informou que entrou na casa pelos fundos, onde tinha um muro

baixo.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, tendo em vista a comprovação da subtração pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas e pelo próprio réu.

No entanto, considerando que o laudo de fls. 144/147, não realizou a perícia nos fundos do imóvel, fato que somado a ausência de visualização da forma de acesso, e a alegação do réu de ter adentrado por um muro baixo, sem ter efetuado transposição de obstáculo, não é possível o reconhecimento da qualificadora da escada, sendo que a dúvida deve ser solucionada em favor do réu, operando-se a desclassificação do delito para furto simples.

APELAÇÃO - Furto qualificado em repouso noturno - Materialidade e autoria demonstradas - Confissão parcial do réu amparada pelos relatos da vítima e do policial civil - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor - Afastamento da qualificadora de escalada - Cabimento - Inexistência de esforço incomum para transpor o muro de 1,65 metros - Exclusão do repouso noturno - Descabimento - Delito praticado durante a madrugada - Menor vigilância sobre o bem - Dosimetria da pena - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu - Manutenção, com a readequação da reprimenda em razão do afastamento da qualificadora da escalada - Confissão espontânea - Reconhecimento - Incidência da Súmula 545 do C. STJ - Compensação com a agravante da reincidência - Pena aumentada de 1/3 em razão da majorante de repouso noturno - Substituição penal não recomenda ao caso - Regime inicial semiaberto - Possibilidade - Crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa - Pena privativa de liberdade inferior a 04 anos - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0005266-38.2016.8.26.0347; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)

Ainda, não há que se falar em crime de bagatela ou insignificância, figura desconhecida no nosso ordenamento jurídico. O pequeno valor da coisa não serve para legitimar o comportamento em questão, mas apenas para eventual abrandamento de pena em caso de furto privilegiado, o que não ocorreu no presente caso.

Na doutrina de Júlio Fabrini Mirabete:

"A excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserida na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 3/345) .

(...) Segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial. (Manual de Direito Penal, 21a. Ed. vol. I, p. 118/119)

E o próprio Mirabete exemplifica:

"É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja o efetivo desfalque do patrimônio alheio". (Idem, vol.II, pág.225/226).

O Desembargador Souza Nery, de forma assaz pertinente, assim coloca a questão:

"Quanto à tese do crime de bagatela, entendo que não se aplica ao caso o chamado princípio da insignificância. O ordenamento jurídico brasileiro não contemplou – malgrado o desejo de muitos – o princípio da bagatela, a cujo respeito já se disse decorrer de verdadeira insignificância de princípios." (TJSP – AC - 990.09.058638-9, 9ª Câmara Criminal, j. 27.08.09).

Da mesma forma, o Desembargador Xavier de Aquino entende que a pequena quantia subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada não tornam atípica a conduta, embora possam, desde que presentes outros requisitos, permitir o reconhecimento do furto privilegiado. De acordo com o eminente Magistrado:

"Pensar de forma diferente seria transformar as ruas em palco de treinamento para delinquentes. Se apanhados permanecem impunes diante da aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, se a conduta é bem sucedida também saem ilesos". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 990.09.218713-9, Americana, 11ª Câmara Criminal, j. 09.12.2009).

Em julgado da apelação nº 0001914-88.2012.8.26.0581, da Comarca de São Manoel-SP, assim decidiram nossos tribunais.

"Tocante à aplicação do princípio da insignificância, deve-se ter em mente que o fato não pode ser considerado atípico somente em decorrência do valor da coisa furtada, ou porque os bens foram recuperados. Para tanto, creio ser indispensável a presença de outros requisitos estabelecidos pela doutrina e pela Jurisprudência: 1) ofensividade mínima; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade; 4) inexpressividade da lesão jurídica causada (STF, HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/05/10; STJ, REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14/06/10; HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de 15/03/10).

O réu é reincidente (certidões de fls. 11/12 do autuado em apenso), ostentando

condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF "O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.

Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal", HC 102.088, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/05/10.

Não se pode confundir baixo grau de lesividade com sua absoluta inexistência, pena de adotar-se, como regra, a impunidade em casos como os em comento. Daí porque se justifica a "persecutio criminis in iudicio".

Nos dias atuais, em que a sociedade presencia o recrudescimento de toda espécie de criminalidade, em que as instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela manutenção da segurança e ordem pública sofrem com o descrédito da população, em que a sensação de insegurança está pulverizada em todo o corpo social, o princípio da insignificância deve ser aplicado com redobrada cautela, devendo constituir exceção e não regra, pois do contrário o Judiciário estará alimentando esse sentimento de desassossego, fomentando o crime e a impunidade.

Pelo que tenho notado a jurisprudência não se pacificou com relação à incidência do princípio. Pelo contrário, atualmente tem passado a analisar o crime sob o enfoque da vítima, sob o prisma de quem está perdendo _ e para quem, via de regra, a conduta é dotada de lesividade. Nesse sentido pronunciou-se o Min. Luiz Fux no julgamento do HC nº 100.690 (Supremo Tribunal Federal): "Eu tenho muita preocupação com essa teoria, porque as jurisprudências dos tribunais têm um caráter exemplificativo para a sociedade. Então, se nós chegamos aqui para dizer que furtar dois DVD's não é crime, nós estamos exatamente tornando antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita". (AC 2014.0000633914, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Orlando, 06.10.2014).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PENAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DA RES PALAVRAS DE TESTEMUNHAS RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL - PENA E REGIME REESTRUTURADOS - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da insignificância, porquanto constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurídicos. - Estando comprovada a autoria do delito pela confissão do agente, apreensão da res furtiva em seu poder e depoimento de testemunhas, a condenação é medida que se impõe. Sendo a apelante primária e a res furtiva de pequeno valor é de se reconhecer o furto privilegiado na espécie nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação nº 990.09.366733-9 - 12ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi - j. 19.05.2010)

FURTO - Bem subtraído que possui valor econômico, ainda que pequeno - Reconhecimento de crime de bagatela - Impossibilidade: 52(a) - Quando o bem subtraído possui valor econômico, ainda que pequeno, é impossível o reconhecimento do crime de bagatela, não se caracterizando o delito do art. 155 do CP apenas quando não se puder avaliar o produto do furto diante da insignificância da lesão jurídica, como na subtração de um ovo, de ramas de mandioca, de folhas de palmeira etc. (Apelação nº 1.101.025/3, Julgado em 14/09/1.998, 12ª Câmara, Relator: José Habice, RJTACRIM 41/170).

No mais, a existência da prática reiterada de crimes, comprovado nos presentes autos com a reincidência e/ou maus antecedentes, impossibilita a análise do

referido benefício.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.194/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, a presença da testemunha que acionou a polícia.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto simples tentado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 50/56) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base, em 1/5 (um quinto), delimitando-a em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 50/56. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena em 1/3 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido, porquanto chegou separar os objetos para a subtração, perfazendo assim um total de 09 (nove) meses e 18 (dezoitos) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal condenar o réu DAGBERTO APARECIDO SOLDERA à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoitos) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 08 (oito) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

P. R. I. C.

Americana, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA